

次の【事例】の甲について、強盗・不同意性交等罪（刑法第241条）の成立を認める見解と明らかに矛盾する記述は、後記1から5までのうちどれか。（改）

【事例】

甲と乙は、V女を不同意性交しようと企て、共謀の上、暴行・脅迫を加えてV女を性交した。その後、乙は、不同意性交されて抗拒不能の状態になった同女に対し、更に執拗にわいせつ行為をしたが、甲は、見張りをしていた。その際、甲は、足下にV女のバッグがあることに気づき、財物奪取の犯意を生じ、乙がわいせつ行為を続けていて甲を見ておらず、また、不同意性交されたことに加え、執拗にわいせつ行為をされたことによってV女が全く反抗できない状態にあることを確認し、バッグ内から現金を取り出して自分のズボンポケットに入れた。（改）

1. 他の目的による暴行・脅迫で被害者が反抗抑圧状態になった後に財物奪取の犯意を生じ、財物を奪取した事例において、犯意を生じた後、財物奪取の手段となる新たな暴行・脅迫が全くなく、単に反抗抑圧状態に乗じて財物を奪取したにすぎない場合に強盗罪の成立を認めることはできないと解すべきである。（改）
2. 他の目的による暴行・脅迫で被害者が反抗抑圧状態になった後に財物奪取の犯意を生じ、財物を奪取した事例において、犯意を生じた後、財物奪取の手段となる新たな暴行・脅迫がある場合は強盗罪の成立を認めることができる。ただし、その暴行・脅迫の程度について、一般的に、通常の強盗の場合に比べ軽い程度のもので足りると解すべきではない。
3. 財物奪取の手段となる新たな暴行・脅迫がある場合に強盗罪の成立を認める点において、2の記述と同じである。なお、その暴行・脅迫の程度について、不同意性交が先行するような事例では、通常の強盗の場合に比べ軽い程度のもので足りる場合があると解すべきである。ただし、新たな暴行・脅迫があるというためには、財物を奪取した行為者自身がその暴行・脅迫を行う必要があると解すべきである。（改）
4. 本件において、不同意性交後の乙のわいせつ行為は、不同意性交の共謀に基づくもので甲も罪責を負うべき共同の暴行行為であると解すべきである。（改）
5. 本件において、仮に、甲が財物奪取の犯意を生じた時点で、V女が不同意性交されて意識を失っていた場合には、窃盗罪が成立するにとどまり、強盗罪の成立を認めることはできないと解すべきである。（改）

（参照条文）刑法

第177条1項 前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は陰若しくは肛門に身体の一部（陰茎を除く。）若しくは物を挿入する行為であつてわいせつなもの（以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。）をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。（改）

* 令和5年刑法改正により、強制性交等罪は「不同意性交等罪」（177条）に改められた。また、強姦犯人が強盗をした場合について、改正前は強姦罪（旧177条）と強盗罪（236条）の併合罪と解されていたが、平成29年改正により、強盗行為と強制性交等行為との先後を問わず強盗・強制性交等罪（241条）が成立することとなった。そして、令和5年刑法改正により、強盗・強制性交等罪は「強盗・不同意性交等罪」に改められた。そのため、問題文、事例、記述1、及び記述3～5にわたって改題した。

1 明らかに矛盾するとはいえない

暴行・脅迫を加え被害者の反抗が抑圧された後の段階で、財物奪取の意思が生じた場合について、犯人が前の暴行によって生じた抵抗不能の状態を利用し、いわばその余勢をかって財物を奪ったものと認められる限り強盗と認めるべきであるとする強盗説と、犯人が財物奪取の意思を生じた後に被害者の拒否を不能ならしめる暴行・脅迫に値する行為がない以上強盗とはいえないとする窃盗説(235条)の対立がある。本記述は窃盗説の理由となる記述である。もっとも、本事例においては財物奪取の意思が生じた後に、甲と共謀している共同正犯者乙が執拗にわいせつ行為をしていることから、新たな暴行・脅迫が全くないとはいえず、強盗説からはもちろん窃盗説からも、甲に強盗・不同意性交等罪の成立を認めることができないわけではない。したがって、本記述は、甲に強盗・不同意性交等罪の成立を認める見解と明らかに矛盾するとはいえない。

2 明らかに矛盾するとはいえない

本記述は、他の目的による暴行・脅迫で被害者が反抗抑圧状態になった後に財物奪取の犯意を生じ、財物を奪取した事例において、犯意を生じた後、財物奪取の手段となる新たな暴行・脅迫がある場合は強盗・不同意性交等罪の成立を認めることができるが、その暴行・脅迫の程度について、一般的に、通常の強盗の場合に比べ軽い程度のもので足りると解すべきではないとする。「通常の強盗の場合」の程度とは、「相手の反抗を抑圧するに足る程度」をいうが、本事例においては、甲の共同正犯者乙が執拗にわいせつ行為をしており、これがV女の反抗を抑圧するに足る程度といえないわけではない。したがって、本記述は、甲に強盗・不同意性交等罪の成立を認める見解と明らかに矛盾するとはいえない。

3 明らかに矛盾する

本記述は、財物奪取の手段となる新たな暴行・脅迫があるというためには、財物を奪取した行為者自身がその暴行・脅迫を行う必要があると解すべきとする。しかし、本事例において、財物を奪取した甲自身は財物奪取の手段となる新たな暴行・脅迫を行っていない。したがって、本記述の見解からは本事例において甲に強盗・不同意性交等罪は成立しない。したがって、本記述は、甲に強盗・不同意性交等罪の成立を認める見解と明らかに矛盾する。

4 明らかに矛盾するとはいえない

本記述は、不同意性交後の乙のわいせつ行為は、不同意性交の共謀に基づくもので甲も罪責を負うべき共同の暴行行為であると解すべきとする。この見解によれば、本事例において、甲は乙のわいせつ行為について罪責を負うため、これをもって甲が新たな暴行・脅迫を行なったといえるから、窃盗説からも甲に強盗・不同意性交等罪の成立を認めることは可能である。したがって、本記述は、甲に強盗・不同意性交等罪の成立を認める見解と明らかに矛盾するとはいえない。

5 明らかに矛盾するとはいえない

本記述は、本件において、仮に、甲が財物奪取の犯意を生じた時点で、V女が不同意性交されて意識を失っていた場合には、窃盗罪が成立するにとどまり、強盗・不同意性交等罪の成立を認めることはできないと解すべきであるとする。これは被害者が失神していれば、脅迫をすることができず新たな暴行を加えることも考え難いことを理由とし、窃盗説からの帰結である。しかし、本事例においては、V女は失神しておらず、甲の共同正犯者乙の執拗なわいせつ行為を新たな暴行・脅迫とみることのできるものであるから、本記述の見解からも甲に強盗・不同意性交等罪の成立を認める

ことができないわけではない。したがって、本記述は、甲に強盗・不同意性交等罪の成立を認める見解と明らかに矛盾するとはいえない。

*問題ページの*で述べたように、平成 29 年改正により、強姦犯人が強盗をした場合について、強盗犯人が強姦をした場合と同様に、強盗・強制性交等罪（現：強盗・不同意性交等罪）（241 条）で処理されることとなった。その場合であっても、本問の議論、すなわち、財物奪取の手段となる新たな暴行・脅迫が必要であるか否か、必要であるとしてもその程度如何等については引き続き議論されるものと考えられる。

なお、平成 29 年改正による強盗・強制性交等罪（241 条）は以下のとおり。

第 241 条 強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強制性交等の罪（第 179 条第 2 項の罪を除く。以下この項において同じ。）（現：第 177 条の罪）若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は強制性交等（現：同条）の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は 7 年以上の拘禁刑に処する。

2 前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を軽減することができる。ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

3 第 1 項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。